

1520584-14.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio. Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, a atitude ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520584-14.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520584-14.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2241219/2020 - 73º Distrito Policial - Jaçanã, 5415/2020 - 73º Distrito Policial - Jaçanã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO BUENO FELIPE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 1251.20

VISTOS.

EDUARDO BUENO FELIPE, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no artigo 33, caput, c.c. artigo 61, II, "j", da Lei 11.343/06, do Código Penal, porque consta, que no dia 29 de setembro de 2020, por volta das 19h20min, durante estado de calamidade pública, na Rua Tenente Sotomano, 1291, Vila Medeiros, nesta cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar 81 (oitenta e um) invólucros plásticos (ependorfs) contendo cocaína com peso líquido de 53,33 g (cinquenta e três gramas e trinta e três centigramas) e 30 (trinta) porções de tetrahydrocannabinol com peso líquido de 76,87g setenta e seis gramas e oitenta e sete centigramas).

Recebida a denúncia à fl. 83.

Apresentada defesa preliminar à fl. 106.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da minorante, a pena no mínimo, regime mais brando e direito de recurso em liberdade. É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, dando conta dos 30 invólucros de maconha, dos 81 invólucros de cocaína, além dos R\$ 170,00, encontrados em poder do réu.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 93, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para cocaína e tetrahydrocannabinol.

A autoria também é inconteste.

De fato, os argumentos da douta defensoria pública não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra ele derivadas, em especial, pelas testemunhas inquiridas e declarações do próprio increpado que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Na Delegacia de Polícia o réu declarou que é usuário de maconha; estava no local quando um indivíduo lhe deu duas parangas e fugiu, foi aí que viu os policiais e colocou as parangas na boca, mas eram só duas e não três; que não sabe informar quem era a pessoa que fugiu e lhe deu a maconha; que os R\$100 eram de sua propriedade, furto do seu trabalho como servente de pedreiro, fls. 04.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu forneceu sua versão dizendo que eu estava vindo do serviço, estava com cem reais e fui na lojinha comprar as duas parangas que estavam na minha mão. Quando o rapaz me deu as parangas, ouvi molhou, molhou. Todo mundo correu, eu fui abordado, mandaram eu cuspir o que tinha na boca, eu cuspi, eram três parangas para meu uso. Era dez reais cada uma, mas não deu tempo de pagar. A carroça não era minha, eu trabalho com obras. Não conhecia os policiais. Tenho 53 anos de idade e sou viciado.

Ocorre porém que os argumentos do acusado não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual, não convenceu.

Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer.

Não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado.

Tanto que o próprio réu, em seu interrogatório, afirmou que não conhecia os policiais. Mesmo porque, não se pode crer que o réu estivesse com tamanha quantidade de drogas em seu poder, não fosse para o exercício da traficância.

Desta forma, não se tem nos autos, um indício sequer que pudesse evidenciar que toda a prova acusatória tivesse sido produzida com a finalidade única de prejudicar o réu ou mesmo acusá-lo falsamente. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio. Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, a atitude suspeita do réu ao avistar os policiais, o local conhecido como ponto de drogas, sua abordagem, a quantidade de drogas encontradas, somado ao relato firme e seguro por parte dos policiais, não deixam dúvidas acerca da traficância.

Tanto é assim que o policial militar responsável pela prisão do réu, Elder Ramon Silva ouvido em Juízo, relatou de forma firme e segura que estávamos em

patrulhamento pelo local, costumeiro pela prática de tráfico, quando vimos o réu introduzir algo na boca e tentar correr da gente. Conseguimos abordá-lo, pedimos para ele cuspir o que tinha colocado na boca, ele cuspiu, vimos que era entorpecente. Na carroça que ele puxava, de reciclagem, encontramos os demais entorpecentes. O réu disse que não sabia do se tratava. Reconheceram o réu e não o conheciam anteriormente. Nós estávamos de patrulhamento em motocicletas. Por sua vez, o policial militar, Antonio Marcio da Rosa Junior, não foi capaz de se recordar dos fatos, porém confirmou seu depoimento prestado na delegacia a fls. 03. Também se recordou do réu, o reconhecendo em Juízo.

Embora o policial Antonio não tenha se recordado dos fatos, seus depoimentos inquisitivos foram devidamente confirmados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, de maneira que as provas dos autos mostram-se robustas e suficientes a embasar a condenação.

Os policiais narraram com segurança e precisão como se deu a prisão do acusado, relatando todos os detalhes, desde patrulhamento de rotina, o momento em que avistaram o réu próximo a uma carroça em atitude suspeita, o momento em que correu e levou as drogas a boca, sua abordagem, o momento em que o réu cuspiu a maconha, o encontro das drogas e dinheiro dentro da carroça, até final detenção e prisão. Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ª T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos, são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Em que pesem, pois, os argumentos da defesa, alegando em síntese que tudo não passou de uma armação para incriminar o réu e que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Neste contexto, em vista da grande quantidade de drogas encontradas em poder do réu, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercância, pudesse vir a inocentar o acusado da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo pois, impossível a absolvição. Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76

- Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canelas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

O fato do réu ser também usuário e estar vendendo para sustentar seu vício, em nada abala a tipificação constante na denúncia. Os chamados traficantes usuários devem ser penalizados, com o mesmo rigor, uma vez que integram a cadeia do tráfico de forma fundamental, pois com o objetivo de conseguirem lucro fácil para sustentarem seus vícios, assumem todos e quaisquer riscos a fim de aliciarem novos clientes e usuários. Destarte, não evidenciou-se qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

Em arremate, não há que se falar na incidência da agravante referente à calamidade pública, tendo em vista que a pandemia que assola a população mundial, em nada afeta os fatos ora tratados nestes autos. Observo que a venda de drogas não sofre qualquer influência pela atual situação pandêmica, ao menos nada há nos autos que comprove o contrário. Nesta esteira de raciocínio, a agravante postulada pelo representante do ministério público há que ser afastada.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie. O acusado é primário, e sem antecedentes criminais, de maneira que fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na hipótese dos autos, forçoso de faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos. E isso porque o acusado primário, sem quaisquer antecedentes, e não há um indício sequer a demonstrar que faça parte de alguma organização criminosa.

Assim, considerando-se a capacidade lesiva de uma das drogas em questão, tratando-se de cocaína, reduzo a pena base em 1/2, perfazendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que " O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida - 13 (treze) pedras de crack - justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3" (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012).

Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que " O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida - 13 (treze) pedras de crack - justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3" (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012).

O valor do dia multa é o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar EDUARDO BUENO FELIPE, como incurso nas penas do artigo 33, §4º da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime aberto a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na hipótese específica destes autos, o regime aberto se justifica tendo em vista que o réu é primário, sem qualquer mácula em sua vida, foi solto no curso do processo e compareceu a todos os atos para os quais foi chamado. Além disso, mostrou arrependido, sendo que fazê-lo retornar aos sistemas carcerários revela medida excessivamente drástica como forma de repressão e retribuição.

De outro giro, não é possível a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantém repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovente deve ser segregado do convívio

social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: "Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: "inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado desta, determino a perda do dinheiro em favor da União. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

(Juíza de Direito)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA